

0005348-02.2022.8.26.0269

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... próximo havia um casal praticando tráfico de drogas. Em razão disso, os policiais se deslocaram até as proximidades e permaneceram a certa distância, perto do banheiro público, instante em que passaram a observar a movimentação do delatado casal. Durante a campana, puderam verificar conduta típica de tráfico, posto que viram Maria entregar uma porção de droga para um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1501362-64.2021.8.26.0571 - Controle 2021/001473

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA e outro

Data da Audiência:

08/09/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes, verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública. Ausentes a ré Maria do Carmo Alves Lourenço Moreira que se encontra em liberdade, tendo sido decretada sua revelia às fls. 265 e o réu Antonio Marcos de Jesus Pereira, citado por edital às fls. 261. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foi ouvida a testemunha Renan Winher Freitas arroladas pelas partes. A Acusação e a Defesa desistiram da oitiva da testemunha Danilo Pereira Rocha, o que foi homologado pelo MM. Juiz. O depoimento foi registrado pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Decorrido o prazo do edital de citação de Antonio Marcos de Jesus Pereira, o acusado não compareceu em Juízo e também não constituiu Defensor. Assim, desmembre-se o feito em relação ao acusado Antonio Marcos de Jesus Pereira e façam-me os autos conclusos. No tocante à ré, não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução e determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, A ré foi denunciada e está sendo processada como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c. c. artigos 29, caput, e 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, pois, no dia 13 de outubro de 2021, por volta das 14 horas e 30 minutos, na Praça Peixoto Gomide, próximo ao nº 395, centro, nesta cidade e comarca de Itapetininga, concluída e agindo em concurso e com unidade de desígnios com terceiro, trazia consigo e guardava, para fornecimento e entrega a consumo, ainda que gratuito: a)16 (dezesseis) porções de "maconha", com peso líquido de

22,00g (vinte e dois gramas), e; b) 06 (seis) porções de “cocaína”, na forma de “crack”, com peso líquido de 1,25g (um grama e vinte e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A ré foi notificada (fls. 130) e apresentou defesa prévia (fls. 167/168). A denúncia foi recebida em 28/01/2022 (fls. 170/171) e a acusada foi citada (fls. 187). Foi decretada a revelia de MARIA DO CARMO (fls. 265). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. A ré não foi interrogada. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), auto de constatação (fls. 19/21) e pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 109/113). A autoria também foi devidamente demonstrada. Vejamos. Na órbita policial, MARIA DO CARMO negou a prática dos fatos. Falou que estava com seu companheiro comendo um salgadinho quando foram abordados pelos policiais. Realizada revista, nada foi encontrado. Notou que os policiais procuraram algo perto de uma banca de jornais. Após, foram levados para próximo da linha férrea, onde mais uma vez os militares realizaram buscas (fls. 08). Em Juízo, a acusada optou pela revelia. A prova oral é suficientemente segura ao incriminá-la. De fato, diz a denúncia que, no dia dos fatos, policiais militares encontravam-se em ponto de estacionamento na Praça Peixoto Gomide, quando uma mulher, que não quis se identificar, informou que ali próximo havia um casal praticando tráfico de drogas. Em razão disso, os policiais se deslocaram até as proximidades e permaneceram a certa distância, perto do banheiro público, instante em que passaram a observar a movimentação do delatado casal. Durante a campana, puderam verificar conduta típica de tráfico, posto que viram Maria entregar uma porção de droga para um usuário, sendo que este, imediatamente, efetuou o pagamento a ANTÔNIO. Em seguida, o casal foi abordado. Com Maria foram encontradas as 06 (seis) porções de “crack” e, bem próximo dela, foram localizadas as 12 (doze) porções de “maconha”, todas embaladas de forma idêntica às 04 (quatro) porções encontradas com ANTÔNIO, prontas para a imediata alienação. Ante a inequívoca situação de flagrante, os policiais deram voz de prisão ao casal, conduzindo-os a solo policial para as demais providências. Pois bem. Agora, o policial disse que recebeu denúncia que dizia do tráfico realizado por um casal. Chegando ao ponto citado, de longe, viram os corréus. Um morador de rua se aproximou e recebeu algo da ré. Ao mesmo tempo, entregou algum numerário para o réu. MARIA trazia consigo 06 (seis) porções de “crack”. Assim, a prova é firme ao incriminar a acusada. Registre-se que nada está a indicar que a testemunha esteja a prejudicar inocente ou a fantasiar sobre as circunstâncias do crime. Suas palavras foram firmes, harmônicas e coerentes, de modo que merecem todo crédito. Note-se que ela foi contundente ao afirmar que viu a prática da mercancia ilegal. Dessa forma, os fatos narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovados. Impõe-se, pois, a integral procedência da ação. Passemos, então, à análise da pena. Observo que a ré não ostenta Maus antecedentes e é primária (fls. 41/43 e 44/47). Na segunda fase, as penas deverão ser agravadas (art. 61, II, “j”, do CP). Cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. O regime prisional deverá ser o inicialmente aberto e nada impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, com decretação do perdimento dos valores apreendidos. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: A Defensoria Pública representa a acusada Maria do Carmo, que foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Ocorre que a pretensão persecutória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável à acusada, pelas razões a seguir. I. DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. Da absolvição por insuficiência de provas. Como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um édito condenatório. Não é, todavia, o que ocorre na hipótese dos autos. Os policiais ratificaram a versão apresentada em solo policial, declarando que abordaram a acusada em decorrência de denúncia anônima. Tiram visto a ré entregando algo para um morador de rua, o qual teria dado

dinheiro para o corréu Antônio. É certo, portanto, que a denúncia não se sustenta: em primeiro lugar, o suposto morador de rua não foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos; em segundo lugar, o suposto denunciante sequer foi minimamente identificado. Apesar de não ter comparecido em juízo, a ré declarou, em solo policial, que “NÃO TRAZIA DROGAS CONSIGO; NEM CRACK NEM MACONHA; NÃO SABE DA PROVENIÊNCIA DA DROGA APRESENTADA NESTE PLANTÃO; ESTAVA COM SEUMARIDO EM FRENTE AO SUPERMERCADO COFESA COMENDO UM SALGADINHO E BEBENDO UM REFRIGERANTE, QUANDO OS POLICIAIS CHEGARAM, MAS NADA FOI LOCALIZADO COM A DECLARANTE OU COM SEU COMPANHEIRO ANTONIO; QUE VIU QUE UM DOS POLICIAIS REMEXEU EM UM MONTE PRÓXIMO À BANCA DE JORNAIS; COM A CHEGADA DE OUTROS POLICIAIS, FORAM COLOCADOS NA VIATURA E DESCERAM ATÉ A LINHA DO TREM, ONDE PASSARAM APROCURAR ALGO E, APÓS QUINZE MINUTOS ACREDITA QUE LOCALIZARAM ALGO, POIS FOI TRAZIDA AO PLANTÃO POLICIAL; QUE PERCEBEU ANTES DE SER ABORDADA, QUE UM RAPAZQUE CONHECE PELO PRENOME DE FÁBIO HAVIA BUSCADO ALGO EM UM MONTE DE FOLHAS PRÓXIMO A BANCA DE JORNAL” (fls. 8). Assim, a acusação se sustenta tão somente no depoimento dos agentes públicos, o que é insuficiente para eventual condenação. A acusação não se desincumbiu o ônus de comprovar os fatos que alega. Tais situações colocam em dúvida a versão apresentada. Diante disso, é o caso de absolvição do réu nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II- DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. Requisitos legais preenchidos. Na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que a acusada é primária e tem bons antecedentes. Ademais, não há prova de que ela participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da primariedade do denunciado. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida”. (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III- TESES SUBSIDIÁRIAS. Em caso de condenação, na primeira fase da dosimetria das reprimendas, cabe ressaltar que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal, eis que a culpabilidade da ação da acusada não extrapola aquela inerente ao respectivo tipo penal, não tendo havido, ainda, maiores consequências da prática delitiva. Outrossim, na segunda fase, pleiteia seja afastada a agravante pleiteada na denúncia, pois a pandemia em nada influenciou na prática delitiva. Finalmente, quanto ao regime inicial, requer que seja fixado regime inicial aberto de cumprimento da pena, nos termos do art. 33 do Código Penal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Pugna-se, por fim, com fundamento no art. 8º, item 2, ‘h’, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. MARIA DO CARMO ALVES LOURENÇO MOREIRA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, “caput”,

da Lei 11.343/06, c.c. o art. 29, do Código Penal, porque, no dia 13 de outubro de 2021, por volta das 14 h e 30 min, na Praça Peixoto Gomide, próximo ao n. 395, centro, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnio com Antônio Marcos de Jesus Pereira, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, dezesseis porções de "maconha", com peso de 22,0 gramas e seis porções de "crack", com peso de 1,25 gramas. A Ré foi notificada, fls. 130. Em 21 de janeiro de 2022 foi concedida a liberdade provisória à Ré Maria do Carmo, fls. 153/154. A Ré apresentou defesa preliminar, fls. 167/168. A denúncia foi recebida, fls. 170/171, e a Ré citada, fls. 187. ANTÔNIO MARCOS DE JESUS PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. o art. 29, do Código Penal, porque, no dia 13 de outubro de 2021, por volta das 14 h e 30 min, na Praça Peixoto Gomide, próximo ao n. 395, centro, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnio com Maria do Carmo Alves Lourenço Moreira, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, dezesseis porções de "maconha", com peso de 22,0 gramas, e seis porções de "crack", com peso de 1,25 gramas. Notificado por edital, fls. 222, o Réu apresentou defesa preliminar, fls. 238/239. A denúncia foi recebida, fls. 249/250 e o Réu, citado por edital, fls. 261. Nas fls. 265 foi decretada a revelia da Ré Maria do Carmo. Durante a audiência de instrução, debates e julgamento, foi ouvida uma testemunha presente. Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a absolvição. É o relatório. DECIDO. Inicialmente registre-se que esta sentença é adstrita à Ré Maria do Carmo. A ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 11/13, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 14/15, no Laudo de Constatação, fls. 19/21, bem como no Exame químico-toxicológico n. 337.116/2021, fls. 109/113, contatando-se a presença dos princípios ativos Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína. Renan Winher Freitas, policial militar, testemunha, disse que foram avisados por uma transeunte sobre um casal que praticava tráfico de entorpecentes em frente ao Supermercado Cofesa; foram ao local e ficaram em observação, quando viram os réus Antônio e Maria; a Ré Maria entregou algo a um morador de rua, que, por sua vez, entregou algo ao Réu Antônio. Fizeram a abordagem e localizaram, com o Acusado, quatro porções de "maconha" e dinheiro. Com a Ré Maria houve apreensão de seis porções de "crack". Próximo aos acusados os policiais encontraram outras porções de "maconha", no chão, escondidas sob folhas secas. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a condenação é medida que se impõe. Com efeito, as policiais estavam em serviço quando receberam informações de uma transeunte da prática de tráfico de entorpecentes; foram ao local e viram a Ré Maria entregar algo a um morador de rua, que, por sua vez, entregou algo ao Réu Antônio; com o Acusado, quatro porções de "maconha" e dinheiro foram encontrados, e, com a Ré Maria, porções de seis "crack"; próximo aos acusados os policiais encontraram outras porções de "maconha", no chão, escondidas sob folhas secas. Destarte, as drogas, pela quantidade, diversidade, forma de separação e pelo número de porções, claramente, eram destinadas ao comércio ilícito. Ademais, os policiais viram o momento em que a Ré Maria entregou algo a um usuário, certamente porção de entorpecente, e esse usuário entregou algo ao Réu, certamente dinheiro. Não se olvida ainda que houve apreensão de dinheiro, fruto de vendas, o que se infere das circunstâncias e da ausência de demonstração lícita. No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais e agentes da lei, há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos. Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe

01/06/2011). Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que a Ré trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, condutas estas que configuram a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de trazer consigo e guardar, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede integralmente. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade da Acusada, passo à dosimetria da pena. - Art. 59, "caput", do Código Penal: Considero boas as circunstâncias judiciais, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. Art. 61 e art. 65, do CP: Não há. Art. 68, do CP: Considerando-se a quantidade de entorpecentes, aplico a causa de diminuição de pena e a reduzo em 2/3. Fixo-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, que torno definitiva. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa "empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo", pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no último dispositivo legal acima mencionado. Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). O Superior Tribunal de Justiça já vem se alinhando àqueles entendimentos, conforme se viu no julgamento do Habeas Corpus 176.919/DF, onde foi concedida a ordem para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e para substituir esta por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2010, DJe 13/12/2010). Na hipótese, o réu havia sido condenado por tráfico de drogas, lhe sendo imposta uma sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, tendo sido reconhecida a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais, o Réu poderá cumprir a pena no regime aberto, já considerada a detração. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Preenchidos os requisitos previstos nos incs. I, II e III, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, e limitação de fim de semana. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar MARIA DO CARMO ALVES LOURENÇO MOREIRA, qualificada nos autos, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário - mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006. Decreto a perda dos valores. Substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade, e limitação de fim de semana. Deixo de condenar a Ré nas custas, ante a pobreza presumida. A Ré respondeu em liberdade ao processo, e, neste momento, ausentes as razões da custódia cautelar, poderá interpor eventual recurso nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-

se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 08 de setembro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA